

1502268-10.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1502268-10.2022.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502268-10.2022.8.26.0542

Controle: 2022/001972

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

LUIZ FERNANDO MATIAS FAUSTINO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

LUIZ FERNANDO MATIAS FAUSTINO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 23 de setembro de 2022, por volta das 11h, na Rua Teotônio Vilela, 96, Santa Maria, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, trazia consigo: 134,63g de maconha, e 9,63g de crack, ambas substâncias entorpecentes, capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que policiais militares diligenciavam pelas imediações do local dos fatos, ocasião em que avistaram indivíduo em circunstância que julgaram suspeita, levando volume junto à cintura, sendo que, ao se dar conta da aproximação policial, ele dispensou uma sacola plástica, ensejando a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado na posse de Luiz Fernando.

Todavia, no interior da sacola por ele dispensada foi localizado o entorpecente, bem como R\$ 21,70 e uma folha de caderno contendo anotações atinentes à contabilidade do tráfico de drogas.

A denúncia foi ofertada, sendo notificado Luiz Fernando (fls. 110). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 115) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2020 (fls. 118/119). Luiz Fernando foi citado (fls. 134).

Em instrução processual criminal foi ouvida testemunha (fls. 151). Houve

desistência da oitiva de testemunha, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 153), prosseguindo-se com o interrogatório (fls. 152).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 153).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Luiz Fernando nos termos da denúncia (fls. 156/159).

A Defesa requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo e a aplicação do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (fls. 261/278).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva se consubstancia em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 29/32), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e laudo de constatação (fls. 19/21), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 241/242) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria (fls. 152).

Perante a D. Autoridade Policial, Luiz Fernando se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 7/8).

Em Juízo, confessou a prática delitiva. Declarou que, como o policial informou na audiência, estava passando e, quando viu a viatura voltando, tirou as drogas e dispensou no chão. Foi abordado. Ainda não tinha vendido droga. Essa era a primeira vez que venderia droga, embora tenha outro tráfico. Declarou seu arrependimento. Trabalhava como mecânico, mas em razão de passagem criminal foi mandado embora. Estava devendo para agiota e suas gêmeas iam nascer. Estava com as drogas e resolveu vender. A única solução que teve foi vender drogas para pagar o agiota (fls. 152).

Inferir-se que a confissão representa idôneo liame entre a autoria e o evento perpetrado, encontrando-se corroborada pelas demais provas produzidas, inclusive pela confissão extrajudicial de autoria. Deve, pois, ser considerada sincera. Neste sentido:

“Confissão Judicial - Ausência de circunstância que evidenciem insinceridade - Suficiência - Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”. (Ap. 470.903-2-SP - 8a C. - TACrim - j. 08.10.87 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida).

Quanto ao alegado estado de necessidade, não há qualquer prova produzida a respeito, além de mera alegação. Ademais, sequer há como aferir se havia outro meio a seguir. Assim sendo, tem-se que inviável a aplicação do artigo 24, do Código Penal.

A testemunha Policial Militar Marcos Aurélio declinou que, em patrulhamento, avistaram o acusado em atitude suspeita e, quando foram fazer a abordagem, ele empreendeu fuga. Acompanharam ele por metros e o acusado entrou em uma viela, sendo detido. Antes de empreender fuga, ele dispensou uma sacola plástica contendo entorpecente. Além do entorpecente havia R\$ 21,00 na sacola. Não havia documentação (fls. 153).

O testemunho policial demonstra a veracidade dos fatos, até porque respondeu às indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias no aspecto principal, quer na fase extrajudicial como em Juízo. Ainda, encontra-se corroborada pela confissão judicial de autoria.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório. “PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos,

además, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial" (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Luiz Fernando. Diante da aproximação policial, ele dispensou objeto. Abordado, com eles nada de ilícito foi encontrado. Recuperado o objeto dispensado, constatou-se ser entorpecente. Informalmente e em Juízo, Luiz Fernando confirmou a traficância. Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Luiz Fernando foi denunciado por trazer consigo substância entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal e consequente condenação de Luiz Fernando por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

Faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso judicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua

Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

É reincidente, ex vi da informação trazida pela certidão criminal de fls. 87, dando conta de anterior condenação, sem que tenha havido o transcurso do quinquênio depurador. Assim, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, a reprimenda será exasperada em 1/6.

Vale anotar que a Lei 11.343/06 não define o que seja reincidência, aplicando-se, portanto, a previsão do Código Penal. Como é bem sabido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, o Código Penal não distingue entre reincidência genérica e específica, usando, tão-somente, o critério temporal.

"Como regra geral, o Código Penal afastou a chamada reincidência específica, sendo suficiente a prática de crime anterior - independentemente das suas características -, que pode ou não ser idêntico ou ter o mesmo bem juridicamente protegido pelo crime posterior, praticado após o trânsito em julgado da sentença condenatória" (GREGO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral, 14. ed., Ímpetus, 2012, p. 568).

"PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DEMULTA. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ALÉM DO FATOR DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 269 STJ. ORDEM EM PARTE CONCEDIDA. 1. O cometimento de novo delito acarreta o reconhecimento da agravante da reincidência em virtude do anteriormente praticado, inexistindo qualquer distinção acerca do tipo de crime perpetrado ou de pena aplicada, nos termos do artigo 63 do Código Penal. 2. A mens legis da norma consiste em apenar de uma forma mais gravosa aquele que apresenta uma tendência à prática delitiva, mesmo que de pequena expressão o crime ou a pena. 3. Imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e favoráveis as circunstâncias judiciais, deve ser aplicado o regime semiaberto ao acusado reincidente. Súmula n.º 269 do STJ. 4. Ordem parcialmente concedida a fim de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente" (HC 235481/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgamento: 17/05/2012, DJe 28/05/2012). Ainda, o reconhecimento da reincidência, como agravante e causa obstativa de

concessão de benefício não constitui bis in idem, conforme o assentado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 196197-RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, Julgamento: 16/8/2021. Publicação: 5/9/12), quanto pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 453.000-RS, Relator Ministro Marco Aurélio, Julgamento: 4/4/2013. Publicação: 3/10/2013).

Não é pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reconhecida reincidência.

“Importante ressaltar que o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº11.343/06, não é direito subjetivo do acusado. O legislador, ao adotar a expressão "poderão", quis demonstrar, com todas as letras, que se trata de mera faculdade do Juiz sentenciante que, na dosimetria da pena, tem, obrigatoriamente, de seguir a diretriz prevista no artigo 42 da referida lei, que demonstra como a pena deve ser aplicada. Em outras palavras, se o legislador entendesse que a benesse acima mencionada era direito do réu, teria usado a palavra "deverão", oriunda do verbo "dever", que significa obrigação, necessidade, etc. Assim, como o texto do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, está redigido que "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços", não há qualquer dúvida que a concessão do benefício depende do livre arbítrio do Juiz, que, como já dissemos acima, tem de levar em consideração o artigo 59, caput, do Código Penal, e também o artigo 42 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (HABEAS CORPUS Nº 293.891 - SP

(2014/0104066-0) - RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ADVOGADO: OTONIEL KATUMI KIKUTI - DEFENSOR PÚBLICO - IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PACIENTE: WESLEI FRANCIMAR DE ABREU).

Cabe, ainda, ressaltar que, não sendo o acusado o produtor da droga, adquire ele o entorpecente de outrem, os quais estão vinculados a atividades criminosas antecedentes (Apelação 0049725-63.2007.8.26.0405 - Relator Amado Faria - 8ª Câmara de Direito Criminal - Tribunal de Justiça de São Paulo - 19/4/2012).

Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na base. Deixo de agravar a reprimenda pela incidência do artigo 61, I, do Código Penal, compensando-o com o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Saliento que a pena está em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras agravantes ou atenuantes. Não há causas de diminuição ou de aumento.

À míngua de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva.

Em face do disposto na Lei 11.464, de 28/3/2007, fixo o regime inicial fechado, com a progressão prevista na referida legislação para o apenado, notadamente reincidente.

Outro regime que não o inicial fechado não será o suficiente para a prevenção e repressão delitivas.

Trata-se de crime de natureza grave, equiparado a delito hediondo, que causa perturbação da ordem pública, atingindo o bem-estar (Saúde) - direito constitucionalmente assegurado e de primordial relevância, sendo o tráfico de drogas a mola propulsora que frontalmente contraria este princípio; além de fomentar outros crimes de elevada gravidade. Verifica-se que Luiz Fernando, definitivamente condenado, volta a delinquir, turbando a Ordem Pública, demonstrando, ainda, que qualquer outro regime, que não o fechado, não bastará à repressão e prevenção delitivas.

Inviável é, outrossim, a aplicação da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. Isto porque o enunciado sumular é claro, somente se cogita adoção do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, o que não é o caso dos autos.

A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, trazida ao Código Penal pela Lei 9.714/98, é incompatível e inaplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, tendo em vista a vedação imposta pela Lei 8.072/90. Ora, admitir-se a substituição da pena privativa de liberdade em crime desse jaez é ignorar o

dever assumido pelo Brasil no combate ao tráfico de entorpecentes.

Se a quantidade da pena imposta e que obsta a substituição, já que superior a quatro anos, esse beneplácito se restringe à pequena e à média criminalidade nos quais não se justifica a retirada do agente da Sociedade, de acordo com a Exposição de Motivos do então Projeto de Lei 689 de 18/12/1996. Não é, pois, passível de extensão a delito assemelhado a hediondo, pela sua reconhecida perniciosidade à Sociedade.

Apesar da grave ameaça ou violência à pessoa não integrar o tipo penal do tráfico de entorpecente, não se pode olvidar que se trata de elemento significativo que flagela a Sociedade.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO LUIZ FERNANDO MATIAS FAUSTINO DE SOUZA, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicialmente fechado, a pena de pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, por incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 11.464/07.

O apenado está preso por força de prisão preventiva e, condenado, não faz jus de recorrer em liberdade, estando legitimada a prisão cautelar.

A jurisprudência, com muita propriedade, consagrou que a periculosidade é presumida:

“O tráfico de tóxico é de tal ordem nocivo à comunidade em geral que, a toda evidência, põe em risco a ordem pública, pelas suas nefandas e terríveis conseqüências. Colocar em liberdade alguém que, preso em flagrante por indiciariamente se entregar à distribuição e venda de tóxico é, sem dúvida, estimular comércio ilícito e altamente pernicioso ao bem-estar social” (TJSP - HC 27166, Relator Nelson Fonseca, RJTSP 88/435).

Destarte, a necessidade da manutenção da prisão está evidenciada para garantida da ordem pública. Recomende-se o sentenciado na prisão onde se encontra em razão de sentença condenatória sem o direito de apelar em liberdade. Expeça-se a guia de recolhimento provisória do condenado, fazendo, oportunamente, os devidos aditamentos.

A teor do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, consigno que o sentenciado está custodiado, por este processo-crime, desde 23 de setembro de 2022 e ainda não faz jus à progressão de regime e/ou detração penal, razão pela qual serão levadas a efeito, tão-somente, pelo Juízo das Execuções Penais.

Nos termos do artigo 60, c.c. o artigo 63, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 125, do Código Penal, atendido ao requisito do artigo 126, do Código Penal, e a teor do artigo 127, do Código Penal, decreto o perdimento do numerário apreendido, dada sua origem ilícita.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos termos regimentais. Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 12 de dezembro de 2022.